Tübingen, 16.10.2026

Matr.-Nr.

7. Semester

Übung im Zivilrecht

für Fortgeschrittene

bei Prof. Dr. Stefan Thomas

Ferienhausarbeit

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis....6
Sachverhalt....7
Gutachten....1
A. Frage 1: Provisionsanspruch der A gegen K aus § 652 I 1 BGB....1
I. Anspruch entstanden....1
1. Zustandekommen eines wirksamen Maklervertrags....1
a) Einigung durch Angebot und Annahme, §§ 145 ff. BGB....1
aa) Angebot durch das Exposé, § 145 BGB....1
bb) Vertragsschluss in den Geschäftsräumen der A....1
b) Einbeziehung und Wirksamkeit der Provisionsklausel....1
aa) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB, § 310 III BGB....2
bb) Provisionsklausel als AGB, § 305 I 1 BGB....2
cc) Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II BGB....2
dd) Keine vorrangige Individualabrede, § 305b BGB....2
ee) Keine überraschende Klausel, § 305c I BGB....2
ff) Inhalts- und Transparenzkontrolle, § 307 BGB....3
gg) Zwischenergebnis zur Provisionsklausel....3
c) Anwendbarkeit der Sondervorschriften der §§ 656a ff. BGB....3
aa) Verbrauchereigenschaft der K, § 656b BGB....3
bb) Einordnung als Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. BGB....3
cc) Zwischenergebnis zur Anwendbarkeit....4
d) Einhaltung der Vorgaben der §§ 656a ff. BGB....4
aa) Wahrung der Textform, § 656a BGB....4
bb) Halbteilungsgrundsatz bei Doppeltätigkeit, § 656c I 1 BGB....5
cc) Zwischenergebnis zu den §§ 656a ff....5
e) Widerruf des Maklervertrags, §§ 355 I, 312g I BGB....5
f) Kündigung des Maklervertrags....5
g) Nichtigkeit infolge Anfechtung, § 142 I BGB....6
aa) Erklärung der Anfechtung, § 143 I, II BGB....6
bb) Vorliegen eines Anfechtungsgrundes, § 119 I BGB....6
cc) Rechtsfolgenirrtum als Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB....6
dd) Zwischenergebnis zur Anfechtung....7
2. Nachweis der Gelegenheit zum Vertragsschluss, § 652 I 1 BGB....7

3. Wirksamer Abschluss des Hauptvertrags....7
4. Ursächlichkeit der Maklertätigkeit....7
5. Höhe der Provision....8
6. Zwischenergebnis zur Entstehung....8
II. Durchsetzbarkeit des Provisionsanspruchs....8
1. Auskunftsanspruch der K aus § 242 BGB....8
2. Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 BGB....9
a) Maklervertrag als Urkunde....9
b) Bezug der Urkunde zu einem Rechtsverhältnis der K....9
c) Rechtliches Interesse an der Einsichtnahme....9
d) Besitz der Urkunde durch A....10
e) Zwischenergebnis zu § 810 BGB....10
3. Einrede des Zurückbehaltungsrechts, § 273 I BGB....10
a) Gegenseitigkeit der Ansprüche....10
b) Konnexität der Ansprüche....10
c) Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Gegenanspruchs....10
d) Rechtsfolge des Zurückbehaltungsrechts, § 274 I BGB....10
e) Zwischenergebnis zu § 273 BGB....11
III. Ergebnis zu Frage 1....11
B. Frage 2: Räumungs- und Herausgabeansprüche der K gegen T....11
I. Räumungsanspruch der K gegen T aus § 546 I BGB....11
1. Eintritt der K in das Mietverhältnis, § 566 I BGB....11
2. Wirksame Beendigung des Mietverhältnisses....11
a) Außerordentliche fristlose Kündigung, § 543 I, II 1 Nr. 3 BGB....12
aa) Mietrückstand und Minderungsrecht, §§ 536, 536b BGB....12
bb) Verzug mit zwei Monatsmieten, § 543 II 1 Nr. 3 lit. b BGB....13
cc) Keine Abmahnung erforderlich, § 543 III 2 Nr. 3 BGB....13
dd) Unwirksamkeit durch Schonfristzahlung, § 569 III Nr. 2 BGB....13
b) Hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung, § 573 BGB....14
aa) Zulässigkeit und Eintritt der Bedingung....14
bb) Berechtigtes Interesse der K, § 573 I 1, II Nr. 1 BGB....14
cc) Schonfristzahlung und ordentliche Kündigung....14
dd) Einhaltung der Kündigungsfrist, § 573c I BGB....15
ee) Form und Begründung, §§ 568 I, 573 III BGB....15

ff) Sozialwiderspruch der T, §§ 574 ff. BGB....15
gg) Zwischenergebnis zur ordentlichen Kündigung....16
3. Ergebnis zum Räumungsanspruch....16
II. Herausgabeanspruch der K gegen T aus § 985 BGB....16
1. Eigentum der K am Grundstück....16
2. Besitz der T an der Wohnung....16
3. Fehlendes Besitzrecht der T, § 986 I BGB....16
4. Ergebnis zu § 985 BGB....16
C. Frage 3: Kautionsrückzahlungsanspruch der T gegen K aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 BGB....17
I. Rückzahlungsanspruch entstanden....17
1. Wirksame Kautionsabrede zwischen V und T, § 551 BGB....17
2. Übergang der Rückgewährpflicht auf K, § 566a S. 1 BGB....17
3. Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe der Wohnung....17
4. Zwischenergebnis zum Rückzahlungsanspruch....17
II. Rückzahlungsanspruch erloschen, § 389 BGB....17
1. Gegenforderung der K aus §§ 280 I, 241 II BGB....17
a) Mietverhältnis als Schuldverhältnis....17
b) Verletzung der Obhutspflicht, § 241 II BGB....18
c) Vertretenmüssen der T, §§ 280 I 2, 276 BGB....18
d) Ersatzfähiger Schaden, § 249 BGB....18
e) Entbehrlichkeit einer Fristsetzung zur Schadensbeseitigung....18
f) Zwischenergebnis zur Gegenforderung....19
2. Wirksame Aufrechnung, §§ 387 ff. BGB....19
a) Gegenseitigkeit von Haupt- und Gegenforderung, § 387 BGB....19
b) Gleichartigkeit infolge der Ersetzungsbefugnis, § 249 II 1 BGB....19
c) Erfüllbarkeit der Haupt- und Fälligkeit der Gegenforderung....19
d) Verjährung der Gegenforderung, §§ 548 I, 390, 215 BGB....20
e) Erklärung der Aufrechnung, § 388 S. 1 BGB....20
f) Wirkung der Aufrechnung, § 389 BGB....21
g) Zwischenergebnis zur Aufrechnung....21
III. Ergebnis zu Frage 3....21
D. Frage 4: Beseitigungsanspruch der N gegen K aus § 1004 I 1 BGB....21
I. Eigentum der N am Nachbargrundstück....21

II. Eigentumsbeeinträchtigung durch die Gebäudereste....21
1. Ursprüngliche Duldungspflicht nach § 912 I BGB....21
a) Überbau bei Errichtung eines Gebäudes....21
b) Weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit des Überbauenden....22
c) Kein sofortiger Widerspruch der N....22
d) Zwischenergebnis zu § 912 I BGB....22
e) Rechtsfolgen des entschuldigten Überbaus....22
2. Fortwirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern V und K....22
3. Erlöschen der Duldungspflicht durch den Teilabriss....23
4. Eigentumslage an den Gebäuderesten....23
5. Zwischenergebnis zur Beeinträchtigung....23
III. Verantwortlichkeit der K als Störerin....23
IV. Kein Ausschluss nach § 1004 II BGB....24
V. Ergebnis zu Frage 4....24

Literaturverzeichnis

Autor Buch

Sachverhalt

V ist Eigentümerin eines bebauten Grundstücks. Auf dem Grundstück befindet sich eine Doppelhaushälfte mit untergeordneter vermieteter Einliegerwohnung sowie ein kleiner Werkstattanbau. V beauftragt Maklerin A schriftlich mit dem Verkauf des Grundstücks. Vereinbart wird eine Provision von 3 % des Kaufpreises. A erstellt ein Exposé. Darin erklärt sie deutlich, dass ihre Maklertätigkeit nicht nur für die Verkäuferseite, sondern auch für die Käuferseite erfolgt (Doppeltätigkeit). Daher habe ein Käufer ebenfalls eine Provision von 3 % des Kaufpreises zu zahlen. K sieht das Exposé und meldet sich bei A. A und K schließen in den Geschäftsräumen der A schriftlich einen Maklervertrag nach einem Formular, welches A seit langem für ihre Kunden standardmäßig benutzt und die marktübliche 3 % Provision des Käufers vorsieht. Die Höhe der vom Verkäufer zu tragenden Provision ist in dem Formular nicht angegeben. K kennt das Grundstück bereits seit längerer Zeit. Sie hat beim Spazierengehen immer wieder ein Auge darauf geworfen und sieht es als interessantes Erwerbsobjekt zu privaten Wohnzwecken an. Von einer Verkaufsabsicht der V und vom Verkaufspreis erfährt K aber erst durch das Exposé. V und K verhandeln anschließend über den Kaufpreis, werden sich aber nicht einig und brechen die Verhandlungen zunächst ab. Nach vier Monaten nehmen sie wieder Kontakt auf und erzielen eine Einigung. K kauft das Grundstück schließlich von V mit notariell beurkundetem Kaufvertrag für EUR 1.000.000. Die Auflassung wird formgerecht erklärt, und K wird im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen. Nun verlangt A von K EUR 30.000 Maklerprovision. K erklärt gegenüber A, sie wolle an den Maklervertrag nicht mehr gebunden sein. Sie habe zwar das Exposé einschließlich der Angabe zur Provisionspflicht gründlich gelesen, habe aber nicht gewusst, was die Provisionspflicht bedeute. K erklärt außerdem, sie werde allenfalls zahlen, wenn A den Maklervertrag mit V vorlegt. A teilt der K lediglich mit, V habe ebenfalls 3 % Provision geschuldet und gezahlt.

In der vermieteten Einliegerwohnung lebt seit sechs Jahren die 82-jährige T. T ärgert sich bereits seit ihrem Einzug über den allmorgendlichen Lärm eines angrenzenden Kindergartens. Dennoch zahlte sie in den ersten vier Jahren vorbehaltlos die volle vereinbarte Miete. Danach zog sie bei den Überweisungen der monatlichen Mietzahlungen eigenmächtig jeweils 40 % ab. Der Kindergarten war bereits vor dem Einzug der T in Betrieb und hält schon immer sämtliche Immissionsrichtwerte ein. Von beidem hatte die T beim Einzug auch Kenntnis. Nach dem Eigentumsübergang auf K zahlt T auch an K weiterhin nur die verminderte Miete. K lässt die Rückstände zunächst sechs Monate auflaufen und kündigt T schließlich schriftlich fristlos,

hilfsweise ordentlich wegen Zahlungsverzugs. Die Zahlungsrückstände werden im Schreiben richtig beziffert. Ein Hinweis auf den Sozialwiderspruch fehlt im Kündigungsschreiben. Da T sich noch am selben Tag weigert, auszuziehen, erhebt K am folgenden Tag in prozessrechtlich zulässiger Form Räumungsklage. Sieben Wochen nach Zustellung der Räumungsklage zahlt T sämtliche Mietrückstände nach. T schreibt der K per Brief, dass die Kündigung schon wegen ihres – der T – hohen Alters nicht rechtmäßig sei. Es liegen bei T keine gesundheitlichen Einschränkungen oder sonstigen Umstände vor, die einen Umzug unmöglich oder unzumutbar machen würden. Weitere acht Monate später fordert K von T erneut Räumung und Herausgabe der Wohnung.

Frage 1: Hat A gegen K einen Anspruch auf Zahlung von EUR 30.000?

Frage 2: Hat K gegen T einen Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Wohnung?

T räumt die Wohnung schließlich doch und gibt sie an K zurück. Bei der Rückgabe der Wohnung entdeckt K erhebliche Beschädigungen an Böden und Türen, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch der Wohnung durch T zurückzuführen sind. Die Beseitigung dieser Schäden würde EUR 2.000 kosten. Acht Monate nach Rückgabe der Wohnung verlangt T von K Rückzahlung ihrer zu Beginn des Mietverhältnisses an V geleisteten Barkaution in Höhe von EUR 2.000, was dem Zweifachen der unveränderten Nettokaltmiete entspricht. K erklärt gegenüber T, sie behalte die Kaution wegen der verursachten Schäden ein. T gibt zwar zu, dass sie die Schäden pflichtwidrig und schuldhaft verursacht hat, wendet aber ein, dass K ihr diesbezüglich keine Frist zur Reparatur gesetzt hat.

Der Werkstattanbau auf dem Grundstück (Stammgrundstück) steht teilweise auf dem Nachbargrundstück, welches sich im Eigentum der N befindet. Errichtet wurde der Anbau durch den Vater der V, der damals Eigentümer des Stammgrundstücks war. Bei der Errichtung war dem Vater der V der Grenzverlauf nicht bekannt. Die Überbauung war trotz sorgfältiger Prüfung der verfügbaren Unterlagen für den Vater der V nicht erkennbar. N hatte der Errichtung des Werkstattanbaus zugesehen und erkannt – anders als der Vater der V –, dass Teile auf ihrem Grundstück stehen. Sie hat der Überbauung aber erst zwei Monate nach der Fertigstellung widersprochen. V wurde schließlich Alleinerbin ihres Vaters. Nachdem K das Grundstück von V erworben hat, lässt K den auf ihrem Grundstück befindlichen Teil des Werkstattanbaus abreißen. Die

auf dem Grundstück der N stehenden Gebäudeteile lässt K stehen. K meint, die Gebäudereste gehörten nun der N. N verlangt dagegen von K die Beseitigung der Reste.

Frage 3: Hat T gegen K einen Anspruch auf Rückzahlung der Kaution?

Frage 4: Kann N von K die Beseitigung der auf dem Grundstück der N verbliebenen Gebäudeteile verlangen?

Gutachten

A. Frage 1: Provisionsanspruch der A gegen K aus § 652 I 1 BGB[1]

A könnte gegen K einen Anspruch auf Maklerlohn in Höhe von 30.000 € aus § 652 I 1 haben. Voraussetzung sind ein wirksamer Maklervertrag, eine Nachweis- oder Vermittlungsleistung der A und der hierauf beruhende Abschluss des Hauptvertrags.

I. Anspruch entstanden

Zunächst müsste der Anspruch entstanden sein.

1. Zustandekommen eines wirksamen Maklervertrags

Zwischen A und K müsste ein wirksamer Maklervertrag bestehen.

a) Einigung durch Angebot und Annahme, §§ 145 ff. BGB

Ein Vertrag setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme, voraus, §§ 145 ff.[2]

aa) Angebot durch das Exposé, § 145 BGB

Bereits das Exposé der A könnte ein Angebot i.S.d. § 145 sein. Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die alle wesentlichen Vertragsbestandteile enthält.[3] Maßgeblich ist, ob ein objektiver Empfänger einen Rechtsbindungswillen erkennen kann, §§ 133, 157.[4] Das Exposé nennt zwar die Käuferprovision von 3 %, richtet sich aber an einen unbestimmten Kreis möglicher Käufer. A wollte sich daher erkennbar nicht gegenüber jedem Leser binden. Das Exposé ist folglich nur eine invitatio ad offerendum.

bb) Vertragsschluss in den Geschäftsräumen der A

Angebot und Annahme könnten aber in den Geschäftsräumen der A erklärt worden sein. Nachdem sich K auf das Exposé hin gemeldet hatte, schlossen A und K dort schriftlich einen Maklervertrag. Eine Einigung liegt somit vor.

b) Einbeziehung und Wirksamkeit der Provisionsklausel

Die formularmäßige Käuferprovision von 3 % müsste nach den §§ 305 ff. wirksam Vertragsbestandteil geworden sein.

---

1 Alle Normen, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, entstammen dem BGB.
2
3
4

aa) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB, § 310 III BGB

Zunächst müssten die §§ 305 ff. anwendbar sein. Eine Bereichsausnahme nach § 310 IV greift nicht. Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher gelten sie mit den Maßgaben des § 310 III.[5] A handelt als gewerbliche Maklerin und ist damit Unternehmerin i.S.d. § 14. K erwirbt das Grundstück zu privaten Wohnzwecken und ist somit Verbraucherin i.S.d. § 13. Es liegt folglich ein Verbrauchervertrag vor.

bb) Provisionsklausel als AGB, § 305 I 1 BGB

Die Provisionsklausel müsste eine AGB sein. AGB sind gem. § 305 I 1 alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen bei Vertragsschluss stellt.[6] A verwendet das Formular mit der vorformulierten Käuferprovision von 3 % seit Langem für ihre Kunden. Ausgehandelt wurde die Klausel nicht. Sie ist somit eine AGB und gilt zudem gem. § 310 III Nr. 1 als von A gestellt.

cc) Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II BGB

Die Klausel müsste gem. § 305 II in den Vertrag einbezogen worden sein. Dafür muss der Verwender bei Vertragsschluss auf die AGB hinweisen und der anderen Partei die zumutbare Kenntnisnahme ermöglichen.[7] Diese muss zudem mit der Geltung einverstanden sein.[8] Die Klausel stand im Formularvertrag, den A der K vorlegte. K konnte sie daher zur Kenntnis nehmen und war durch den Vertragsschluss mit ihr einverstanden. Die Klausel ist somit einbezogen.

dd) Keine vorrangige Individualabrede, § 305b BGB

Eine vorrangige Individualabrede i.S.d. § 305b ist nicht ersichtlich.

ee) Keine überraschende Klausel, § 305c I BGB

Die Klausel dürfte nicht überraschend i.S.d. § 305c I sein. Das setzt voraus, dass sie objektiv ungewöhnlich ist und der Vertragspartner subjektiv nicht mit ihr rechnen musste.[9] Objektiv ungewöhnlich ist eine Klausel, die deutlich von dem abweicht, was im redlichen Geschäfts-

5
6
7
8
9

verkehr üblich ist.[10] Subjektiv überraschend ist sie, wenn ihr Inhalt erheblich von den berechtigten Erwartungen des Vertragspartners abweicht.[11] Eine Käuferprovision von 3 % ist marktüblich. Zudem hatte A im Exposé, das K gründlich gelesen hatte, deutlich auf die Käuferprovision hingewiesen. K musste somit mit der Klausel rechnen. Sie ist folglich nicht überraschend.

ff) Inhalts- und Transparenzkontrolle, § 307 BGB

Die Klausel müsste schließlich der Inhaltskontrolle standhalten. Dieser unterliegen AGB gem. § 307 III 1 nur, soweit sie von Rechtsvorschriften abweichen oder diese ergänzen.[12] Preisabreden über die Hauptleistung sind daher grundsätzlich kontrollfrei.[13] Die Höhe der Maklerprovision ist gesetzlich nicht festgelegt, sodass die Käuferprovision von 3 % eine kontrollfreie Preisabrede ist. Gem. § 307 III 2 bleibt aber das Transparenzgebot des § 307 I 2 anwendbar, wonach AGB klar und verständlich sein müssen.[14] Für K war eindeutig erkennbar, dass sie bei Abschluss des Kaufvertrags 3 % des Kaufpreises schuldet. Dass die Verkäuferprovision im Formular fehlt, betrifft nicht die Klarheit der Käuferprovision, sondern nur die Überprüfbarkeit des § 656c I (dazu unter II.). Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot liegt folglich nicht vor.

gg) Zwischenergebnis zur Provisionsklausel

Die Provisionsklausel ist somit wirksamer Vertragsbestandteil.

c) Anwendbarkeit der Sondervorschriften der §§ 656a ff. BGB

Weiterhin könnten die §§ 656a ff. anwendbar sein.

aa) Verbrauchereigenschaft der K, § 656b BGB

K müsste Verbraucherin sein. Gem. § 656b gelten die §§ 656c, 656d nur, wenn der Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses Verbraucher ist.[15] Als private Erwerberin ist K somit Verbraucherin.

bb) Einordnung als Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. BGB

Zudem müsste das Kaufobjekt ein Einfamilienhaus sein. Fraglich ist, ob die Doppelhaushälfte trotz der vermieteten Einliegerwohnung und des

10
11
12
13
14
15

Werkstattanbaus noch als solches anzusehen ist. Ein Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. ist ein Gebäude, das in erster Linie den Wohnzwecken der Mitglieder eines einzelnen Haushalts dient.[16] Hierunter können auch Doppelhaushälften fallen.[17] Umstritten ist, nach welchem Maßstab dieser Wohnzweck zu bestimmen ist.[18] Nach einer Ansicht kommt es auf die objektive bauliche Beschaffenheit und die Verkehrsanschauung an. Hierfür spricht die Rechtssicherheit, da die Einordnung nicht von den Vorstellungen des einzelnen Erwerbers abhängt.[19] Nach anderer Ansicht ist der konkrete, für den Makler erkennbare Erwerbszweck des Käufers maßgeblich. Angeführt wird vor allem der Verbraucherschutzzweck der §§ 656a ff.[20] Objektiv steht die Wohnnutzung der Doppelhaushälfte im Vordergrund. Die vermietete Einliegerwohnung ist ausdrücklich untergeordnet und der Werkstattanbau nur klein, sodass beide hinter der Nutzung durch einen Haushalt zurücktreten. Auch nach dem Erwerbszweck liegt ein Einfamilienhaus vor, da K das Objekt zu privaten Wohnzwecken erwerben möchte. Dies war für A bei einer privaten Interessentin, die eine Doppelhaushälfte erwerben will, auch erkennbar. Da beide Ansichten zum selben Ergebnis führen, kann der Streit dahinstehen. Das Kaufobjekt ist somit ein Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff.

cc) Zwischenergebnis zur Anwendbarkeit

Der Anwendungsbereich der §§ 656a ff. ist somit eröffnet.

d) Einhaltung der Vorgaben der §§ 656a ff. BGB

Der Maklervertrag müsste die Vorgaben der §§ 656a ff. einhalten.

aa) Wahrung der Textform, § 656a BGB

Der Maklervertrag müsste gem. § 656a in Textform geschlossen worden sein.[21] Diese erfordert gem. § 126b eine lesbare Erklärung, die die Person des Erklärenden nennt und auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben wird.[22] A und K schlossen den Vertrag schriftlich. Die strengere Schriftform wahrt zugleich die Textform.[23] Die Form des § 656a ist somit gewahrt.

16
17
18
19
20
21
22
23

bb) Halbteilungsgrundsatz bei Doppeltätigkeit, § 656c I 1 BGB

Da A für beide Seiten tätig wurde, müsste sie zudem den Halbteilungsgrundsatz des § 656c I 1 beachtet haben. Danach darf sich ein Makler, der für beide Parteien des Kaufvertrags tätig wird, von beiden nur einen Maklerlohn in gleicher Höhe versprechen lassen.[24] Er muss dabei nicht gleichzeitig von beiden Seiten beauftragt werden, sondern kann auch nacheinander für sie tätig werden.[25] A wurde zunächst von V und dann, wie im Exposé angekündigt, von K beauftragt und vereinbarte mit beiden jeweils 3 % des Kaufpreises. Die Vorgabe des § 656c I 1 ist somit eingehalten. Überprüfen kann K dies mangels Kenntnis des Vertrags mit V aber nicht (dazu unter II.).

cc) Zwischenergebnis zu den §§ 656a ff.

Die Vorgaben der §§ 656a ff. sind somit gewahrt.

e) Widerruf des Maklervertrags, §§ 355 I, 312g I BGB

Die Erklärung der K, sie wolle an den Maklervertrag nicht mehr gebun den sein, könnte ein Widerruf gem. § 355 I sein. Dieser setzt ein gesetz liches Widerrufsrecht voraus.[26] Ein solches hat der Verbraucher gem. § 312g I nur bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen nach § 312b und bei Fernabsatzverträgen nach § 312c.[27] A und K schlossen den Vertrag bei gleichzeitiger Anwesenheit in den Geschäfts räumen der A, nachdem sich K auf das Exposé hin selbst an A gewandt hatte. Weder § 312b I 1 Nr. 3 noch § 312c greift daher ein. K steht somit kein Widerrufsrecht zu.

f) Kündigung des Maklervertrags

Die Erklärung der K könnte ferner als Kündigung des Maklervertrags auszulegen sein, §§ 133, 157. Eine Kündigung wirkt allerdings nur für die Zukunft und lässt den Provisionsanspruch für einen Hauptvertrag unberührt, der bereits vor ihrem Zugang geschlossen wurde.[28] K gab ihre Erklärung erst nach dem Kaufvertrag mit V und dem Zahlungsverlangen der A ab. Eine etwaige Kündigung stünde dem Anspruch daher nicht entgegen.

24
25
26
27
28

g) Nichtigkeit infolge Anfechtung, § 142 I BGB

Schließlich könnte der Maklervertrag gem. § 142 I von Anfang an nich tig sein, wenn K ihre Willenserklärung wirksam angefochten hat.

aa) Erklärung der Anfechtung, § 143 I, II BGB

Zunächst müsste K die Anfechtung gegenüber A als ihrer Vertragspartnerin erklärt haben, § 143 I, II. Der Begriff Anfechtung muss dabei nicht verwendet werden.[29] Es genügt, dass der Erklärende erkennbar macht, das Geschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten lassen zu wollen.[30] K erklärte gegenüber A, sie wolle an den Vertrag nicht mehr gebunden sein, weil sie nicht gewusst habe, was die Provisionspflicht bedeute. Damit hat sie die Anfechtung erklärt.

bb) Vorliegen eines Anfechtungsgrundes, § 119 I BGB

Weiterhin bedarf es eines Anfechtungsgrundes, hier allein eines Irrtums nach § 119 I. Ein Erklärungsirrtum gem. § 119 I Alt. 2 liegt vor, wenn der Erklärende eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, etwa weil er sich verschreibt.[31] Bei einem Inhaltsirrtum gem. § 119 I Alt. 1 weiß der Erklärende, was er erklärt, irrt aber über die Bedeutung seiner Erklärung.[32] K hat den Maklervertrag nach gründlicher Lektüre des Exposés bewusst abgeschlossen. Dass sie sich verschrieben hat, ist nicht ersichtlich. Ein Erklärungsirrtum scheidet somit aus. Ob ihre Aussage, sie habe nicht gewusst, „was die Provisionspflicht bedeu te“, einen Inhaltsirrtum begründet, hängt davon ab, ob ein beachtlicher Rechtsfolgenirrtum vorliegt.

cc) Rechtsfolgenirrtum als Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB

K könnte einem beachtlichen Rechtsfolgenirrtum unterlegen sein. Ein solcher liegt vor, wenn das Geschäft eine wesentlich andere als die vorgestellte Rechtsfolge auslöst.[33] Problematisch ist, wann ein solcher Irrtum als Inhaltsirrtum beachtlich und wann er bloß unbeachtlicher Motivirrtum ist.[34] Beachtlich ist er nur, wenn sich die Fehlvorstellung auf eine Rechtsfolge bezieht, die unmittelbarer Inhalt der Erklärung ist.[35] Knüpft die Rechtsfolge dagegen nur mittelbar kraft Gesetzes an das

29
30
31
32
33
34
35

Geschäft an, ist der Irrtum unbeachtlich.[36] K wusste aus dem Exposé, dass auch die Käuferseite 3 % des Kaufpreises zahlen muss, und schloss dann einen Vertrag mit genau dieser Provisionsabrede. Die Zahlungspflicht als unmittelbarer Erklärungsinhalt war ihr somit bekannt. Ihre erst nach der Zahlungsaufforderung geäußerte Unkenntnis betrifft allenfalls weitere gesetzliche Folgen. Es liegt folglich nur ein unbeachtlicher Motivirrtum vor.

dd) Zwischenergebnis zur Anfechtung

Mangels Anfechtungsgrundes ist der Vertrag nicht gem. § 142 I nichtig. Zwischen A und K besteht somit ein wirksamer Maklervertrag.

2. Nachweis der Gelegenheit zum Vertragsschluss, § 652 I 1 BGB

A müsste ferner die geschuldete Maklerleistung erbracht haben. Nach § 652 I 1 genügt der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss des Hauptvertrags oder dessen Vermittlung.[37] Ein Nachweis liegt vor, wenn der Makler dem Kunden die konkrete Möglichkeit zum Abschluss des angestrebten Hauptvertrags aufzeigt.[38] Einem Nachweis könnte entgegenstehen, dass K das Grundstück von Spaziergängen bereits seit Längerem kannte. Die bloße Kenntnis des Objekts ist aber von der Kenntnis der konkreten Vertragsgelegenheit zu unterscheiden.[39] An Letzterer fehlt es, solange der Kunde nichts von der Verkaufsbereitschaft des Eigentümers weiß.[40] Von der Verkaufsabsicht der V und dem Kaufpreis erfuhr K erst durch das Exposé der A. A hat ihr die Vertragsgelegenheit somit nachgewiesen.

3. Wirksamer Abschluss des Hauptvertrags

Weiterhin müsste der Hauptvertrag wirksam zustande gekommen sein. Maßgeblich ist der Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags.[41] Auf dessen Durchführung kommt es nicht an.[42] Der Grundstückskaufvertrag zwischen V und K über 1.000.000 € wurde gem. § 311b I 1 notariell beurkundet und ist somit wirksam.

4. Ursächlichkeit der Maklertätigkeit

Der Hauptvertrag müsste ferner infolge der Nachweistätigkeit der A

36
37
38
39
40
41
42

zustande gekommen sein, § 652 I 1.[43] Eine die Kausalität ausschließende Vorkenntnis der K bestand nicht (s.o.). Fraglich ist aber, ob der Ursachenzusammenhang entfallen ist, weil V und K ihre Verhandlungen abbrachen und erst vier Monate später wieder aufnahmen. Eine bloß vorübergehende Unterbrechung genügt hierfür nicht.[44] Entscheidend ist, ob zwischen Maklerleistung und Vertragsschluss noch ein angemessener zeitlicher Zusammenhang besteht.[45] Ein Abstand von bis zu einem Jahr kann dabei noch angemessen sein.[46] Hier lagen nur vier Monate zwischen Abbruch und Wiederaufnahme, und der Vertrag betraf genau das nachgewiesene Grundstück. Der Ursachenzusammenhang besteht somit fort.

5. Höhe der Provision

A und K vereinbarten 3 % des Kaufpreises von 1.000.000 €. Der Anspruch besteht somit in Höhe von 30.000 €.

6. Zwischenergebnis zur Entstehung

Der Provisionsanspruch der A ist somit entstanden.

II. Durchsetzbarkeit des Provisionsanspruchs

Fraglich ist, ob A den Anspruch auch durchsetzen kann, da K die Zahlung von der Vorlage des Vertrags zwischen A und V abhängig macht.

1. Auskunftsanspruch der K aus § 242 BGB

K könnte gegen A aus § 242 ein Anspruch auf Auskunft über die mit V vereinbarte Provision zustehen, da sie ohne Kenntnis dieses Vertrags nicht prüfen kann, ob A den Halbteilungsgrundsatz des § 656c I 1 einge halten hat. Da § 656c keinen ausdrücklichen Auskunftsanspruch enthält, ist umstritten, ob sich ein solcher aus § 242 ergibt.[47] Teilweise wird er bejaht, wenn der Maklerkunde zur Kontrolle der Halbteilung auf Informationen des Maklers angewiesen ist.[48] Nach anderer Ansicht fehlt mangels gesetzlicher Regelung eine Grundlage.[49] Für die erste Ansicht spricht, dass K die Einhaltung des zwingenden § 656c I 1 sonst nicht prüfen kann, während A die Auskunft ohne unbillige Belastung erteilen kann. K hat daher einen Auskunftsanspruch aus § 242. Mit der Mittei-

43
44
45
46
47
48
49

lung, V habe ebenfalls 3 % geschuldet und gezahlt, hat A zwar Auskunft erteilt. Überprüfen kann K diese Behauptung aber nicht. Fraglich ist daher, ob sie zudem Einsicht in den Vertrag verlangen kann.

2. Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 BGB

K könnte gegen A ein Anspruch auf Einsicht in den Maklervertrag zwischen A und V aus § 810 Fall 2 zustehen.

a) Maklervertrag als Urkunde

Der Maklervertrag zwischen A und V müsste eine Urkunde sein. Urkunde i.S.d. § 810 ist jede durch Niederschrift verkörperte Gedankenerklärung, die Aussagen über ein Rechtsgeschäft oder Rechtsverhältnis enthält.[50] Der schriftliche Vertrag hält die Provision der V von 3 % fest und ist somit eine Urkunde.

b) Bezug der Urkunde zu einem Rechtsverhältnis der K

In der Urkunde müsste ein Rechtsverhältnis beurkundet sein, an dem K beteiligt ist, § 810 Fall 2.[51] K ist aber nicht Partei des Vertrags zwischen A und V. Die Urkunde muss das Rechtsverhältnis des Anspruchstellers jedoch nicht selbst dokumentieren.[52] Ausreichend ist, dass sie objektiv und unmittelbar mit diesem Rechtsverhältnis zusammenhängt.[53] Wegen der Doppeltätigkeit der A hängt die Wirksamkeit der Provisionsabrede mit K gem. § 656c I 1 davon ab, dass V eine Provision in gleicher Höhe versprochen hat. Gerade dies dokumentiert der Vertrag zwischen A und V. Die erforderliche Beziehung besteht somit.

c) Rechtliches Interesse an der Einsichtnahme

Weiterhin bedarf es eines rechtlichen Interesses der K an der Einsicht. Ein solches besteht, wenn die Einsicht zur Förderung, Erhaltung oder Verteidigung rechtlich geschützter Interessen erforderlich ist.[54] Eine bloße Ausforschung aufgrund vager Vermutungen genügt nicht.[55] Ob die Forderung der A über 30.000 € besteht, hängt nach § 656c von der Provisionsabrede mit V ab, die A nur behauptet. K will damit keine Vermutungen ausforschen, sondern eine Voraussetzung ihrer eigenen Zahlungspflicht prüfen. Ein rechtliches Interesse liegt somit vor.

50
51
52
53
54
55

d) Besitz der Urkunde durch A

Schließlich müsste A die Urkunde besitzen.[56] A ist Vertragspartnerin der V und besitzt die Urkunde somit mangels gegenteiliger Anhaltspunkte.

e) Zwischenergebnis zu § 810 BGB

K kann somit gem. § 810 Fall 2 Einsicht in den Maklervertrag zwischen A und V verlangen.

3. Einrede des Zurückbehaltungsrechts, § 273 I BGB

K könnte die Zahlung gem. § 273 I bis zur Gewährung der Einsicht ver weigern. Das Zurückbehaltungsrecht muss als Einrede geltend gemacht werden.[57] Dies hat K mit der Erklärung getan, sie werde allenfalls nach Vorlage des Vertrags mit V zahlen.

a) Gegenseitigkeit der Ansprüche

Zunächst müsste K als Schuldnerin ein Gegenanspruch gegen die Gläu bigerin A zustehen.[58] Der Provisionsforderung der A steht der Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 gegenüber. Die Ansprüche sind somit gegenseitig.

b) Konnexität der Ansprüche

Der Gegenanspruch müsste aus demselben rechtlichen Verhältnis stam men.[59] Ein einheitlicher Vertrag ist nicht erforderlich. Es genügt ein enger tatsächlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang.[60] Der Einsichtsanspruch soll gerade klären, ob A die Provision von K nach § 656c I 1 verlangen kann. Beide Ansprüche wurzeln in der Doppeltätigkeit der A und sind somit konnex.

c) Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Gegenanspruchs

Der Gegenanspruch müsste wirksam, fällig und durchsetzbar sein.[61] Der Einsichtsanspruch ist entstanden und gem. § 271 I sofort fällig. Ein reden der A sind nicht ersichtlich, sodass er auch durchsetzbar ist.

d) Rechtsfolge des Zurückbehaltungsrechts, § 274 I BGB

Fraglich ist, welche Wirkung das Zurückbehaltungsrecht hier hat. Grundsätzlich muss der Schuldner gem. § 274 I nur Zug um Zug gegen

---

56
57
58
59
60
61

Erfüllung des Gegenanspruchs leisten.[62] Anders liegt es ausnahmsweise, wenn der Gegenanspruch gerade der Überprüfung der Hauptforderung dient. Dann kann der Gläubiger die Leistung vorerst überhaupt nicht verlangen, sodass eine Zahlungsklage nicht zu einer Verurteilung Zug um Zug, sondern zur Abweisung führen würde.[63] K benötigt die Einsicht, um zu prüfen, ob A § 656c I 1 eingehalten hat. Andernfalls wäre die Provisionsabrede mit K gem. § 656c II 1 unwirksam. A kann die Zahlung daher derzeit nicht verlangen, solange sie K die Einsicht nicht gewährt.

e) Zwischenergebnis zu § 273 BGB

K steht somit ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 I zu.

III. Ergebnis zu Frage 1

Der Provisionsanspruch der A gegen K aus § 652 I 1 über 30.000 € ist zwar entstanden. Solange A der K keine Einsicht in den Maklervertrag mit V gewährt, kann sie ihn wegen des Zurückbehaltungsrechts aus § 273 I aber nicht durchsetzen.

B. Frage 2: Räumungs- und Herausgabeansprüche der K gegen T

I. Räumungsanspruch der K gegen T aus § 546 I BGB

K könnte von T gem. § 546 I die Räumung und Herausgabe der Einliegerwohnung verlangen. Dies setzt ein beendetes Mietverhältnis zwischen K und T voraus.

1. Eintritt der K in das Mietverhältnis, § 566 I BGB

Zunächst müsste zwischen K und T ein Mietverhältnis bestanden haben. T hatte die Wohnung von V gemietet. K könnte aber gem. § 566 I eingetreten sein. Danach tritt der Erwerber vermieteten Wohnraums, der nach der Überlassung an den Mieter veräußert wird, anstelle des Vermieters in das Mietverhältnis ein.[64] Veräußerung meint dabei die Übertragung des Eigentums.[65] T bewohnte die Wohnung bereits, als K das Grundstück gem. §§ 873 I, 925 durch Auflassung und Eintragung erwarb. K ist somit in das Mietverhältnis eingetreten.

2. Wirksame Beendigung des Mietverhältnisses

Das Mietverhältnis müsste beendet worden sein. K kündigte schriftlich

62
63
64
65

fristlos und hilfsweise ordentlich wegen Zahlungsverzugs.

a) Außerordentliche fristlose Kündigung, § 543 I, II 1 Nr. 3 BGB

Das Mietverhältnis könnte durch die fristlose Kündigung beendet worden sein. Diese setzt gem. § 543 I 1 einen wichtigen Grund voraus. Ein solcher liegt gem. § 543 I 2 vor, wenn dem Kündigenden unter Abwägung aller Umstände die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zu seinem regulären Ende nicht zuzumuten ist.[66] Für den Zahlungsverzug regelt § 543 II 1 Nr. 3 besondere Kündigungsgründe.[67] Die gem. § 568 I schriftlich erklärte Kündigung nennt mit den bezifferten Rückständen zugleich ihren Grund, § 569 IV.

aa) Mietrückstand und Minderungsrecht, §§ 536, 536b BGB

Zunächst müsste T mit der Miete in Rückstand geraten sein. Dies wäre nicht der Fall, wenn sie gem. § 536 I wegen des Kindergartenlärms zur Minderung berechtigt war. Ein Mangel ist jede für den Mieter nachteili ge Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten Beschaffenheit, welche die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch beeinträchtigt.[68] Auch Geräusche von einem Nachbargrundstück können einen Mangel begründen.[69] Fehlt eine Beschaffenheitsvereinbarung, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen, welche Belastung der Mieter hinnehmen muss.[70] Muss der Vermieter die Immissionen selbst gem. § 906 entschädigungslos dulden, liegt regelmäßig kein Mangel vor.[71] Eine Vereinbarung zwischen V und T über die Geräuschbelastung ist nicht ersichtlich. Der Kindergarten war bereits vor dem Einzug der T in Betrieb und hält seit jeher alle Immissionsrichtwerte ein, sodass gem. § 906 I 2 in der Regel nur eine unwesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Die Geräusche sind folglich hinzunehmen und begründen keinen Mangel. Zudem hat der Mieter gem. § 536b keine Rechte aus §§ 536, 536a, wenn er den Mangel bei Vertragsschluss kennt oder die Mietsache in Kenntnis des Mangels vorbehaltlos annimmt.[72] T kannte den Kindergarten bereits bei ihrem Einzug, sodass eine Minderung auch danach ausgeschlossen wäre. Ob sie ein Minderungsrecht zudem durch die vierjäh

66
67
68
69
70
71
72

rige vorbehaltlose Zahlung verloren hätte, kann offenbleiben. T schuldete somit die volle Miete, sodass durch die Kürzung um 40 % Rückstände entstanden.

bb) Verzug mit zwei Monatsmieten, § 543 II 1 Nr. 3 lit. b BGB

T müsste in dem von § 543 II 1 Nr. 3 lit. b vorausgesetzten Umfang in Verzug sein. Danach muss der Mieter in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit einem Betrag in Verzug sein, der die Miete für zwei Monate erreicht.[73] Da die Miete gem. § 556b I bis zum dritten Werktag des Monats zu entrichten ist, bedurfte es gem. § 286 II Nr. 1 keiner Mahnung.[74] Ein Rechtsirrtum schließt das Vertretenmüssen nach § 286 IV nur aus, wenn er unvermeidbar war.[75] Dafür ist hinsichtlich des vermeintlichen Minderungsrechts der T nichts ersichtlich. Nach dem Eigentumsübergang zahlte T an K sechs Monate lang nur 60 % der Miete. Maßgeblich sind allein diese Rückstände, da K gem. § 566 I nur in die während der Dauer ihres Eigentums entstehenden Rechte eintritt. Frühere Rückstände stehen weiterhin V zu.[76] Der Rückstand erstreckt sich somit über mehr als zwei Termine und beträgt 6 × 40 % = 2,4 Monatsmieten. Dass K die Rückstände sechs Monate auflaufen ließ, schadet nicht, da die §§ 543, 569 die Kündigung wegen Zahlungsverzugs abschließend regeln und § 314 III daher nicht anwendbar ist.[77] Die Voraussetzungen des § 543 II 1 Nr. 3 lit. b liegen folglich vor.

cc) Keine Abmahnung erforderlich, § 543 III 2 Nr. 3 BGB

Eine Abmahnung, die § 543 III 1 grundsätzlich verlangt,[78] war gem. § 543 III 2 Nr. 3 bei Zahlungsverzug entbehrlich.[79]

dd) Unwirksamkeit durch Schonfristzahlung, § 569 III Nr. 2 BGB

Die Kündigung könnte jedoch gem. § 569 III Nr. 2 S. 1 unwirksam geworden sein. Danach wird eine auf § 543 II 1 Nr. 3 gestützte Kündigung unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546a I befrie-

73
74
75
76
77
78
79

digt wird.[80] Die Rechtshängigkeit tritt gem. §§ 253 I, 261 I ZPO mit Zustellung der Klage ein. T beglich sämtliche Rückstände sieben Wochen nach Zustellung der Räumungsklage und damit innerhalb der Frist. Mangels gegenteiliger Angaben ist davon auszugehen, dass die Zahlung auch die fällige Nutzungsentschädigung nach § 546a I umfass te, sodass K vollständig befriedigt wurde. Ein Ausschluss nach § 569 III Nr. 2 S. 2 ist nicht ersichtlich. Die fristlose Kündigung hat ihre Wirkung somit nachträglich verloren.

b) Hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung, § 573 BGB

Das Mietverhältnis könnte aber durch die hilfsweise ordentliche Kündi gung nach § 573 geendet haben.

aa) Zulässigkeit und Eintritt der Bedingung

Fraglich ist zunächst, ob K die ordentliche Kündigung unter einer Bedingung erklären durfte. Als einseitiges Gestaltungsrecht ist die Kündigung grundsätzlich bedingungsfeindlich, da der Empfänger Klarheit über die Rechtslage benötigt.[81] Zulässig ist aber eine Rechtsbedingung, deren Eintritt allein von der rechtlichen Beurteilung abhängt, weil sie für den Empfänger keine Ungewissheit schafft.[82] Die ordentliche Kündigung sollte nur gelten, falls die fristlose Kündigung das Mietverhältnis nicht beendet. Für T war damit klar erkennbar, dass K das Mietverhältnis jedenfalls beenden will. Die Bedingung ist somit zulässig und zudem eingetreten, da die fristlose Kündigung gem. § 569 III Nr. 2 unwirksam geworden ist.

bb) Berechtigtes Interesse der K, § 573 I 1, II Nr. 1 BGB

K müsste gem. § 573 I 1 ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses haben. Ein solches liegt gem. § 573 II Nr. 1 insbe sondere vor, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat.[83] T kürzte die Miete sechs Monate lang unberechtigt und schuldhaft (s.o.). Ein Rückstand von 2,4 Monatsmieten ist nicht unerheblich. K hat somit ein berechtigtes Interesse.

cc) Schonfristzahlung und ordentliche Kündigung

Fraglich ist, ob die Nachzahlung auch die ordentliche Kündigung un-

80
81
82
83

wirksam macht. Die Vorschrift des § 569 III Nr. 2 betrifft ausdrücklich nur die außerordentliche fristlose Kündigung.[84] Auf eine daneben erklärte ordentliche Kündigung erstreckt sie sich nicht.[85] Die Nachzahlung kann allenfalls bei der Gewichtung der Pflichtverletzung im Rahmen des § 573 II Nr. 1 zugunsten des Mieters berücksichtigt werden.[86] T hatte die Miete aber sechs Monate lang eigenmächtig gekürzt und erst nach Klageerhebung nachgezahlt. Das berechtigte Interesse der K bleibt daher bestehen.

dd) Einhaltung der Kündigungsfrist, § 573c I BGB

Weiterhin müsste die Kündigungsfrist eingehalten sein. Diese verlängert sich für den Vermieter gem. § 573c I 2 nach fünf Jahren seit der Überlassung um drei Monate.[87] T wohnte seit sechs Jahren in der Wohnung, sodass eine Frist von sechs Monaten galt. Der genaue Zugang der Kündigung ist unbekannt. Als K die Räumung acht Monate später erneut verlangte, war die Frist aber jedenfalls abgelaufen und das Mietverhältnis somit beendet.

ee) Form und Begründung, §§ 568 I, 573 III BGB

Die Kündigung müsste zudem formgerecht erklärt und begründet sein. Gem. § 568 I bedarf sie der Schriftform, also der eigenhändigen Unterschrift, § 126 I.[88] Die Gründe für das berechtigte Interesse sind gem. § 573 III 1 im Kündigungsschreiben anzugeben. K kündigte schriftlich und bezifferte die Rückstände zutreffend. Form und Begründung sind somit gewahrt.

ff) Sozialwiderspruch der T, §§ 574 ff. BGB

T könnte der Kündigung gem. § 574 I 1 widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn dessen Beendigung für sie eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Ihren Brief, die Kündigung sei wegen ihres hohen Alters nicht rechtmäßig, kann man als schriftlichen Widerspruch i.S.d. § 574b I 1 auslegen. Ob der Widerspruch schon gem. § 574 I 2 ausgeschlossen ist, weil ein Grund zur frist losen Kündigung vorlag, kann offenbleiben, wenn es an einer Härte

84
85
86
87
88

fehlt. Ein hohes Lebensalter fließt zwar in die Abwägung ein,[89] begründet für sich genommen aber keine Härte.[90] Maßgeblich sind vielmehr die konkreten Folgen eines Umzugs für den Mieter.[91] Bei der 82-jährigen T bestehen weder gesundheitliche Einschränkungen noch sonstige Umstände, die ihr einen Umzug unzumutbar machen. Eine Härte liegt somit nicht vor. Der fehlende Hinweis auf den Sozialwiderspruch nach § 568 II macht die Kündigung nicht unwirksam.[92] Gem. § 574b II 2 kann T den Widerspruch dann aber noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits erklären.[93] Mangels Härte bliebe ein Widerspruch der T somit in jedem Fall erfolglos.

gg) Zwischenergebnis zur ordentlichen Kündigung

Die ordentliche Kündigung hat das Mietverhältnis somit mit Ablauf der Kündigungsfrist beendet.

3. Ergebnis zum Räumungsanspruch

T ist somit gem. § 546 I verpflichtet, die Einliegerwohnung zu räumen und an K herauszugeben.

II. Herausgabeanspruch der K gegen T aus § 985 BGB

Daneben könnte K gegen T ein Anspruch auf Herausgabe der Einlieger wohnung aus § 985 zustehen.

1. Eigentum der K am Grundstück

K erwarb das Grundstück gem. §§ 873 I, 925 und damit gem. §§ 93, 94 I auch das Gebäude samt Einliegerwohnung. Sie ist somit Eigentümerin.

2. Besitz der T an der Wohnung

T übt als Bewohnerin die tatsächliche Gewalt über die Wohnung aus und ist somit gem. § 854 I unmittelbare Besitzerin.

3. Fehlendes Besitzrecht der T, § 986 I BGB

T dürfte gegenüber K kein Recht zum Besitz haben, § 986 I. Ein Besitz recht aus einem Mietverhältnis endet mit dessen Beendigung.[94] Das Mietverhältnis mit T ist beendet. T hat somit kein Besitzrecht.

4. Ergebnis zu § 985 BGB

K kann somit auch gem. § 985 die Herausgabe der Wohnung verlangen.

89
90
91
92
93
94

C. Frage 3: Kautionsrückzahlungsanspruch der T gegen K aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 BGB

T könnte von K die Rückzahlung der an V gezahlten Kaution von 2.000 € aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 verlangen.

I. Rückzahlungsanspruch entstanden

Zunächst müsste der Rückzahlungsanspruch entstanden sein.

1. Wirksame Kautionsabrede zwischen V und T, § 551 BGB

Erforderlich ist eine wirksame Kautionsabrede zwischen V und T. Gem. § 551 I darf die Sicherheit höchstens das Dreifache der Monatsmiete ohne Betriebskosten betragen.[95] Die Barkaution von 2.000 € entspricht der doppelten Nettokaltmiete. Die Abrede ist somit wirksam.

2. Übergang der Rückgewährpflicht auf K, § 566a S. 1 BGB

Die Rückgewährpflicht müsste auf K übergegangen sein. Gem. § 566a S. 1 tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten ein, die durch die vom Mieter geleistete Sicherheit begründet worden sind.[96] K ist somit zur Rückgewähr der von T an V geleisteten Kaution verpflichtet, soweit sie diese nicht für eigene Ansprüche verwenden darf.

3. Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe der Wohnung

Zudem müsste das Mietverhältnis beendet und die Wohnung zurückgegeben sein.[97] Beides ist nach der ordentlichen Kündigung (s. Frage 2) und der Räumung durch T der Fall.

4. Zwischenergebnis zum Rückzahlungsanspruch

Der Rückzahlungsanspruch der T ist somit entstanden.

II. Rückzahlungsanspruch erloschen, § 389 BGB

Der Anspruch könnte jedoch durch Aufrechnung der K gem. § 389 erlo schen sein.

1. Gegenforderung der K aus §§ 280 I, 241 II BGB

K könnte gegen T wegen der Schäden an Böden und Türen ein Schadensersatzanspruch über 2.000 € aus §§ 280 I, 241 II zustehen.

a) Mietverhältnis als Schuldverhältnis

Zwischen K und T bestand das gem. § 566 I übergegangene Mietverhältnis. Da K nur in die während ihres Eigentums entstehenden Rechte eintritt (s. Frage 2), ist mangels gegenteiliger Angaben davon auszuge-

95
96
97

hen, dass T die Schäden in dieser Zeit verursachte. Andernfalls stünde der Anspruch der V zu.

b) Verletzung der Obhutspflicht, § 241 II BGB

T müsste eine Pflicht aus dem Mietverhältnis verletzt haben. Aus § 241 II folgt die Pflicht des Mieters, die Mietsache schonend zu behandeln und Schäden zu vermeiden, die über den vertragsgemäßen Gebrauch hinausgehen.[98] Durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigte T Böden und Türen erheblich. Sie hat somit ihre Obhutspflicht verletzt.

c) Vertretenmüssen der T, §§ 280 I 2, 276 BGB

Das Vertretenmüssen wird gem. § 280 I 2 vermutet. Zudem räumt T ein, die Schäden pflichtwidrig und schuldhaft verursacht zu haben. Sie hat die Pflichtverletzung somit zu vertreten.

d) Ersatzfähiger Schaden, § 249 BGB

Der K müsste durch die Pflichtverletzung ein ersatzfähiger Schaden entstanden sein. Schaden ist jede unfreiwillige Einbuße an rechtlich geschützten Gütern.[99] Die Beschädigungen an Böden und Türen mindern den Wert der Mietsache, ihre Beseitigung würde 2.000 € kosten. Ein Schaden liegt somit vor.

e) Entbehrlichkeit einer Fristsetzung zur Schadensbeseitigung

Fraglich ist, ob der Anspruch, wie T einwendet, eine vorherige Fristsetzung voraussetzt. Eine solche ist gem. § 281 I 1 nur erforderlich, wenn wegen der Verletzung einer Leistungspflicht Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird.[100] Die Pflicht des Mieters zur schonenden Behandlung der Mietsache ist aber eine nicht leistungsbezogene Nebenpflicht i.S.d. § 241 II.[101] Ihre Verletzung begründet einen Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung unmittelbar aus § 280 I, für den kei ne Fristsetzung vorgesehen ist.[102] Der Geschädigte kann daher nach seiner Wahl gem. § 249 I Herstellung oder gem. § 249 II 1 sofort den erforderlichen Geldbetrag verlangen, ohne dem Schädiger zuvor Gelegenheit zur Reparatur geben zu müssen.[103] K verlangt Ersatz für bereits entstandene Schäden. Einer Fristsetzung bedurfte es somit nicht.

98
99
100
101
102
103

f) Zwischenergebnis zur Gegenforderung

K hat somit gegen T einen Anspruch auf 2.000 € aus §§ 280 I, 241 II.

2. Wirksame Aufrechnung, §§ 387 ff. BGB

Mit diesem Anspruch könnte K gegen den Rückzahlungsanspruch der T aufgerechnet haben. Dies setzt eine Aufrechnungslage i.S.d. § 387, das Fehlen von Ausschlussgründen und eine Aufrechnungserklärung gem. § 388 voraus.[104]

a) Gegenseitigkeit von Haupt- und Gegenforderung, § 387 BGB

Die Forderungen müssten zwischen denselben Personen in umgekehrter Richtung bestehen.[105] K schuldet T die Kaution, T schuldet K Schadensersatz. Die Forderungen sind somit gegenseitig.

b) Gleichartigkeit infolge der Ersetzungsbefugnis, § 249 II 1 BGB

Weiterhin müssten die Forderungen ihrem Gegenstand nach gleichartig sein.[106] Der Rückzahlungsanspruch ist auf Geld gerichtet, der Schadensersatzanspruch gem. § 249 I hingegen zunächst auf Herstellung.[107] Bei Beschädigung einer Sache kann der Gläubiger jedoch gem. § 249 II 1 statt der Herstellung den erforderlichen Geldbetrag verlangen.[108] Diese Ersetzungsbefugnis muss er ausüben, um den Anspruch als Geldforderung geltend zu machen.[109] Mit der Erklärung, sie behalte die Kaution wegen der Schäden ein, verlangte K Geld statt Reparatur und übte die Ersetzungsbefugnis damit konkludent aus. Die Forderungen sind somit gleichartig.

c) Erfüllbarkeit der Haupt- und Fälligkeit der Gegenforderung

Die Hauptforderung müsste erfüllbar, die Gegenforderung fällig sein.[110] Der Rückzahlungsanspruch ist mit Beendigung des Mietverhältnisses erfüllbar. Fällig wird er erst nach einer angemessenen Prüfungs- und Abrechnungsfrist, in der der Vermieter klären kann, ob er die Kaution für eigene Ansprüche benötigt.[111] Diese Frist war acht Monate nach Rückgabe jedenfalls abgelaufen, zumal K die Schäden schon bei der Rückgabe festgestellt hatte. Der Schadensersatzanspruch der K war

104
105
106
107
108
109
110
111

gem. § 271 I mit Eintritt des Schadens fällig. Beide Voraussetzungen liegen somit vor.

d) Verjährung der Gegenforderung, §§ 548 I, 390, 215 BGB

Die Gegenforderung dürfte nicht einredebehaftet sein. Gem. § 390 kann mit einer einredebehafteten Forderung nicht aufgerechnet werden, wobei schon das Bestehen der Einrede genügt.[112] Ersatzansprüche des Vermieters wegen Verschlechterungen der Mietsache verjähren gem. § 548 I in sechs Monaten ab Rückgabe der Mietsache.[113] Als K acht Monate nach Rückgabe erklärte, die Kaution einzubehalten, war der Anspruch somit verjährt. Gem. § 215 schließt die Verjährung die Aufrechnung aber nicht aus, wenn der Anspruch noch nicht verjährt war, als erstmals aufgerechnet werden konnte.[114] Problematisch ist, dass die Forderungen erst durch die Ausübung der Ersetzungsbefugnis gleichartig wurden und K diese erst nach Ablauf der Verjährungsfrist ausübte. Nach ihrem Sicherungszweck ist die Barkautionsabrede aber so auszulegen, dass der Vermieter die Ersetzungsbefugnis erst im Rahmen der Kautionsabrechnung ausüben muss.[115] Denn die Barkaution soll dem Vermieter nach Mietende einen einfachen Zugriff zur Befriedigung seiner Ansprüche verschaffen.[116] Die Forderungen standen sich daher schon bei Rückgabe der Wohnung und damit vor Eintritt der Verjährung aufrechenbar gegenüber. Folglich hindert die Verjährung die Aufrechnung gem. § 215 nicht.

e) Erklärung der Aufrechnung, § 388 S. 1 BGB

K müsste die Aufrechnung gem. § 388 S. 1 gegenüber T erklärt haben. Der Begriff Aufrechnung muss dabei nicht verwendet werden.[117] Es genügt, dass der Wille, die eigene mit der fremden Forderung zu verrechnen, für den Empfänger erkennbar ist.[118] Die Erklärung der K, sie behalte die Kaution wegen der Schäden ein, bringt aus Sicht der T gem. §§ 133, 157 gerade diesen Willen zum Ausdruck. Die Aufrechnung ist somit erklärt.

112
113
114
115
116
117
118

f) Wirkung der Aufrechnung, § 389 BGB

Gem. § 389 erlöschen die Forderungen, soweit sie sich decken, rückwir kend zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich erstmals aufrechenbar gegen- überstanden. Beide betragen 2.000 € und erlöschen somit vollständig.

g) Zwischenergebnis zur Aufrechnung

Der Rückzahlungsanspruch der T ist somit durch Aufrechnung erlo- schen.

III. Ergebnis zu Frage 3

T hat gegen K keinen Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution.

D. Frage 4: Beseitigungsanspruch der N gegen K aus § 1004 I 1 BGB

N könnte von K gem. § 1004 I 1 die Beseitigung der auf ihrem Grund- stück verbliebenen Reste des Werkstattanbaus verlangen.

I. Eigentum der N am Nachbargrundstück

N ist Eigentümerin des beeinträchtigten Nachbargrundstücks.

II. Eigentumsbeeinträchtigung durch die Gebäudereste

Ferner müsste das Eigentum der N beeinträchtigt sein. Eine Beeinträch tigung i.S.d. § 1004 I ist jeder dem Inhalt des Eigentums widersprechen de Zustand, der nicht in einer Entziehung oder Vorenthaltung des Besit zes besteht.[119] Die Einwirkung darf nach Dauer und Intensität nicht völ- lig unerheblich sein.[120] Die Reste des Werkstattanbaus nehmen dauer- haft Fläche des Grundstücks der N in Anspruch und schränken dessen Nutzung ein. Eine Beeinträchtigung liegt somit grundsätzlich vor. Frag lich ist aber, ob N diesen Zustand nach den Vorschriften über den Über bau dulden muss.

1. Ursprüngliche Duldungspflicht nach § 912 I BGB

N könnte gem. § 912 I zur Duldung verpflichtet gewesen sein. Danach muss der Nachbar einen Überbau dulden, wenn der Eigentümer bei Er- richtung eines Gebäudes ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit über die Grenze gebaut und der Nachbar nicht vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung widersprochen hat.[121]

a) Überbau bei Errichtung eines Gebäudes

Zunächst müsste ein Überbau vorliegen. Ein solcher ist gegeben, wenn

119
120
121

ein einheitliches Gebäude, das vom Stammgrundstück aus errichtet wird, die Grenze überschreitet.[122] Der Vater der V errichtete als damaliger Eigentümer des Stammgrundstücks den Werkstattanbau, der teilweise auf dem Grundstück der N steht. Damit ist ein Überbau gegeben.

b) Weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit des Überbauenden

Dem Vater der V dürfte weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.[123] Vorsätzlich handelt, wer weiß, dass er über die Grenze baut.[124] Dem Vater der V war der Grenzverlauf unbekannt, sodass er nicht vorsätzlich handelte. Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt und schon naheliegende Überlegungen nicht anstellt.[125] Der Vater der V hatte die verfügbaren Unterlagen sorgfältig geprüft, ohne dass die Grenzüberschreitung erkennbar war. Ihm fällt somit auch keine grobe Fahrlässigkeit zur Last.

c) Kein sofortiger Widerspruch der N

N dürfte nicht vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung widerspro chen haben.[126] Sie erkannte bereits während der Errichtung, dass Teile des Anbaus auf ihrem Grundstück entstanden, widersprach aber erst zwei Monate nach der Fertigstellung. Ihr Widerspruch war somit nicht rechtzeitig.

d) Zwischenergebnis zu § 912 I BGB

Die Voraussetzungen des § 912 I waren bei Errichtung des Anbaus somit erfüllt.

e) Rechtsfolgen des entschuldigten Überbaus

Der Nachbar muss den entschuldigten Überbau dulden und ist gem. § 912 II 1 durch eine Geldrente zu entschädigen.[127] Der hinübergebaute Gebäudeteil bleibt zudem dem Stammgrundstück zugeordnet und steht im Eigentum von dessen jeweiligem Eigentümer.[128] N war somit zur Duldung verpflichtet.

2. Fortwirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern V und K

Die Duldungspflicht müsste auch gegenüber K fortgewirkt haben. Als

122
123
124
125
126
127
128

dingliche Beschränkung des Eigentums besteht sie gegenüber dem jeweiligen Eigentümer des Stammgrundstücks.[129] Dieses ging gem. § 1922 I auf V als Alleinerbin und sodann auf K über. Die Duldungspflicht wirkte somit auch zugunsten der K.

3. Erlöschen der Duldungspflicht durch den Teilabriss

Die Duldungspflicht könnte jedoch durch den Teilabriss erloschen sein. Die Vorschrift des § 912 soll verhindern, dass wirtschaftliche Werte durch die Zerschlagung eines einheitlichen Gebäudes vernichtet werden. Geschützt ist also der Bestand des grenzüberschreitenden Gebäudes als wirtschaftliche Einheit.[130] K ließ den auf ihrem Grundstück stehenden Teil des Anbaus abreißen und hob diese Einheit damit selbst auf. Die verbliebenen Reste bilden kein Gebäude mehr, dessen Erhalt § 912 sichern könnte. Mit dem Schutzzweck der Norm ist somit auch die Duldungspflicht der N entfallen.

4. Eigentumslage an den Gebäuderesten

Fraglich ist weiter, wem die Gebäudereste gehören. K meint, sie gehörten nun der N. Gem. § 94 I sind Gebäude zwar wesentliche Bestandteile des Grundstücks, auf dem sie stehen.[131] Beim Überbau gilt nach den §§ 912 ff. jedoch eine abweichende Zuordnung zum Stammgrundstück.[132] Diese Zuordnung bleibt auch nach Abriss des auf dem Stammgrundstück stehenden Teils bestehen.[133] Die Reste sind folglich nicht Bestandteil des Grundstücks der N geworden. Die Auffassung der K trifft somit nicht zu, sie ist Eigentümerin der Gebäudereste geblieben.

5. Zwischenergebnis zur Beeinträchtigung

Das Eigentum der N ist somit durch die Gebäudereste beeinträchtigt, ohne dass N diese nach § 912 I dulden muss.

III. Verantwortlichkeit der K als Störerin

K müsste Störerin sein. Handlungsstörer ist, wer die Beeinträchtigung durch sein Verhalten adäquat verursacht hat.[134] Zustandsstörer ist, wer sie zwar nicht herbeigeführt hat, aber durch seinen maßgebenden Willen aufrechterhält.[135] Er muss die Störung beseitigen können und sie

129
130
131
132
133
134
135

muss ihm zurechenbar sein.[136] Den Anbau hat zwar nicht K, sondern der Vater der V errichtet. K ist aber Eigentümerin der Reste und kann sie beseitigen. Zudem hat sie durch den Teilabriss selbst bewirkt, dass aus dem zu duldenden Überbau eine nicht mehr zu duldende Beeinträchtigung wurde, und lässt die Reste bewusst stehen. Die Beeinträchtigung ist ihr somit zurechenbar. K ist folglich jedenfalls Zustandsstörerin.

IV. Kein Ausschluss nach § 1004 II BGB

Nach Wegfall der Pflicht aus § 912 I ist N somit auch nicht gem. § 1004 II zur Duldung verpflichtet.

V. Ergebnis zu Frage 4

N kann von K gem. § 1004 I 1 die Beseitigung der Reste verlangen.

136